



Roj: **SAN 6289/2022 - ECLI:ES:AN:2022:6289**

Id Cendoj: **28079230042022100888**

Órgano: **Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **4**

Fecha: **07/12/2022**

Nº de Recurso: **661/2019**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **MARCIAL VIÑOLY PALOP**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA NACIONAL

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN CUARTA

Núm. de Recurso: 0000661 /2019

Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General: 10033/2019

Demandante: Epifanio

Procurador: VICTORIO VENTURINI MEDINA

Demandado: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL

Abogado Del Estado

Ponente Ilmo. Sr.: D. MARCIAL VIÑOLY PALOP

SENTENCIA Nº :

Ilma. Sra. Presidenta:

D^a. MARÍA ASUNCIÓN SALVO TAMBO

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. SANTOS HONORIO DE CASTRO GARCIA

D^a. CARMEN ALVAREZ THEURER

D. MARCIAL VIÑOLY PALOP

D^a. ANA MARTÍN VALERO

Madrid, a siete de diciembre de dos mil veintidós.

Vistos los autos del recurso contencioso administrativo nº **661/19** que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido por D. Epifanio , representado por el Procurador **D. Victorio Venturini Medina**, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 11 de marzo de 2019 por la que se estimó parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Regional (TEAR) de 17 de diciembre de 2015 por la que se desestimaron las reclamaciones acumuladas núms. NUM000 y NUM001 , interpuestas contra acto de liquidación provisional de la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT de Madrid, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ejercicio 2011, y contra el correspondiente acuerdo sancionador.

Siendo parte demandada la Administración General del Estado, representada por la Abogacía del Estado.



ANTECEDENTE DE HECHO

PRIMERO.- Por la parte recurrente expresada se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado en fecha 16 de julio de 2019 contra las resolución antes mencionada, fue admitido a trámite por decreto con reclamación del expediente administrativo.

SEGUNDO.- Una vez recibido el expediente administrativo y en el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó demanda, mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2020, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos oportunos, terminó suplicando:

<< dando a los autos la sustanciación oportuna y dictando en su día sentencia por la que, estimando íntegramente el presente recurso anule el acto administrativo recurrido por ser contrario a Derecho, todo ello en base a los fundamentos fácticos y jurídicos contenidos en el cuerpo del presente escrito de demanda y con expresa condena en costas>>..

TERCERO.- La Abogacía del Estado contestó a la demanda, mediante escrito presentado en fecha 23 de diciembre de 2019, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso confirmando íntegramente la resolución impugnada.

CUARTO.- Se presentó por las partes escrito de conclusiones, tras lo cual quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo.

QUINTO.- Se señaló para votación y fallo el día 30 de noviembre de 2022, fecha en que tuvo lugar.

SEXTO.- La cuantía del recurso se ha fijado en 843.126,41 euros.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Marcial Viñoly Palop, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal de Don Matías, como sucesor de D. Epifanio, se recurre la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 11 de marzo de 2019 por la que se estimó parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de 17 de diciembre de 2015 por la que se desestimaron las reclamaciones acumuladas núms. NUM000 y NUM001, interpuestas contra acto de liquidación provisional de la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT de Madrid, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ejercicio 2011, y contra el correspondiente acuerdo sancionador.

SEGUNDO.- Es de tener en cuenta, a los efectos de la resolución del presente procedimiento, los antecedentes descritos en la resolución objeto del presente recurso:

- Por Acuerdo de liquidación de 7/07/2014, dirigido a la comprobación de las ganancias patrimoniales producidas por determinada enajenación inmobiliaria, se concluyó que D. Epifanio, en el ejercicio 2011, tiene su residencia habitual en territorio español, y por tanto, era contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En segundo lugar, se constató que el obligado tributario D. Epifanio vendió un inmueble sito en el término municipal de DIRECCION000 (Mallorca) a la sociedad ARAMOS PROPIEDADES SLU por un importe de 8.000.000 euros, sin que constara que D. Epifanio, con NIF NUM002 hubiera presentado declaración por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes ni declaración por IRPF en ningún ejercicio.

Se estableció que la fecha de adquisición fue el 13 de enero de 1989, que el coste de adquisición fue de 429.723,66 euros, que tras aplicar el coeficiente de 1,2908 fijado en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, para aquellas inversiones realizadas con anterioridad a 31 de diciembre de 1994, daba un de adquisición actualizado es de 554.687,30 euros (429.723,66 euros x 1,2908).

Del precio de venta se redujo el importe de todos aquellos costes asociados a la operación por importe de 498.700,47 euros.

Se fijó como fecha de transmisión fecha en la que se formaliza la escritura de 08 de febrero de 2011 y el precio de venta es de 7.501.299,53 euros (8.000.000 euros - 498.700,47 euros).

La correspondiente liquidación procedió a dar el siguiente resultado:

Cuota 468.172,07

Recargos 0,00

Intereses de Demora 47.233,90

Deuda a ingresar / a devolver 515.405,97

- Interpuesta reclamación económico-administrativa, por resolución del TEAR de 17/12/2015 se procedió a su desestimación.

- Interpuesto recurso de alzada ante el TEAC, por resolución de 11/03/2019, ahora impugnada se procedió a su estimación parcial en base a los siguientes razonamientos:

1. Respecto de la falta de audiencia, se afirma que "Por el TEAC se ha comprobado que tanto el escrito de alegaciones fechado a 18/06/14, que se presentó el mismo día a las 12:01 horas en el RGTO MARÍA DE MOLINA, como el escrito de alegaciones de 05/06/14, forman parte del expediente electrónico remitido por la AEAT tras su configuración por la Inspección."

2. Respecto de la falta de respuesta a las alegaciones realizadas se afirma que, si bien es cierto que en el acto de liquidación no figura respuesta expresa a las alegaciones formuladas el 18.06.14, ello no quiere decir que no exista suficiente respuesta jurídica implícita a tales alegaciones en relación con la residencia en Perú del obligado tributario en relación a Perú ello impide la aplicación del IRPF/2011 español, así como gastos inherentes a la compra de la finca urbana en 1989, y gastos relacionados con la venta en el 2011.

3. Respecto de la residencia fiscal existen indicios y pruebas de que ha estado en España mas de 183 días.

4. Respecto de los gastos derivados de la adquisición de la finca urbana y de su venta, a los efectos de ganancias patrimonial, se afirma que no aprecia irregularidad o defecto alguno respecto del coste de adquisición fijado por la Inspección al no constar acreditados el importe abonado en concepto de ITP y AJD.

5. Respecto de los costes asociados a la venta se concluye que el valor de transmisión está erróneamente calculado por cuanto que eran cuatro, y no dos como consideró la Inspección, las facturas emitidas por North Mallorca Real Estate SL por la mediación y gestión de venta del inmueble que constan en el expediente por un importe de 472.000 euros, importe que será el que deba tenerse en cuenta como gasto deducible en el importe de la venta del inmueble realizada por el contribuyente. Por ello, Procede, por tanto, la anulación del acto de liquidación provisional, a fin de que se fije un valor de transmisión de 7.459.808 euros (resultado de restar de los 8.000.000 euros de precio convenido gastos por importe de 540.192 euros, 68.192 por la cuota del Impuesto municipal sobre el IVTNU y 472.000 euros por el importe de las facturas recibidas en concepto de comisión de la agencia inmobiliaria, del 6,35%, por servicios de intermediación en la venta de la finca) y, en consecuencia, se practique nuevo acto de liquidación en sustitución del anterior del que resulte que son inferiores los importes de la cuota, de los intereses de demora y, en consecuencia, de la deuda tributaria a ingresar por el IRPF/2011.

6. En relación al acuerdo sancionador, habiéndose acordado la anulación del acto de liquidación provisional (a fin de que rectificando el error material advertido se fije el valor de transmisión de la finca en 7.423.808 euros, en lugar de los 7.501.299,53 euros de la liquidación anulada) procede, en consecuencia, estimar en parte la reclamación anulando el acuerdo sancionador, que deberá sustituirse por otro nuevo ajustando la base sancionadora a la cuota que resulte del nuevo acto de liquidación provisional por el IRPF/2011.

TERCERO.- Al ega el recurrente en su demanda.

- Nulidad de la resolución impugnada por vulneración del art. 34 de la LGT que reconoce el derecho del obligado tributario a formular alegaciones y a aportar documentación en cualquier momento del procedimiento y a que sea contemplada en la resolución.

- Que el recurrente tiene su residencia en Perú.

- Que al costo de adquisición de la vivienda hay que sumar los gastos e impuestos en que se ha incurrido como consecuencia de la declaración de obra nueva, así como el importe del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales por la adquisición y de notario y de registro.

El Abogado del Estado interesa la desestimación del presente recurso.

CUARTO.- Vu lneración del art. 34.1 LGT.

Se alega que el trámite de audiencia se notificó el 23 de mayo de 2014, por lo que el plazo para formular alegaciones finalizaba el 4 de junio; sin embargo, la Sra. Actuaria había hecho constar en la Diligencia del trámite de audiencia que la firma de las actas debía realizarse el 5 de junio, de donde se deduce que la inspección tenía claro que fueran cuales fueren las alegaciones que se formularan y la documentación que se aportara, la decisión estaba tomada.

Se solicitó, además, la ampliación del plazo para realizar alegaciones. Se solicitó igualmente retrasar la hora de la firma de las Actas al objeto de poder presentar alegaciones y documentación que, esta parte quería

incorporar al expediente, que fueron presentadas en el Registro a las 12:38 horas. No obstante, a las 13:57 horas se firma el Acta y el expediente sancionador y se hace entrega de una copia de las alegaciones.

Se añade que, con fecha 11 de junio durante el trámite de alegaciones posterior a la firma de las Actas, se volvió a solicitar ampliación del plazo para su formulación, alegaciones que se realizaron con fecha 18 de junio. Sin embargo, el Acuerdo de Liquidación de la Oficina Técnica se limita a transcribir las alegaciones formuladas el 18 de junio y a obviar las del día 5.

Se concluye afirmando que "Ninguna de las cuatro instancias administrativas a las que ha recurrido el obligado tributario ha tenido a bien resolver esta circunstancia, que no es otra que la negativa a presentar alegaciones y documentación adicional, aún más, las cuatro se han "abstenido" de dar respuesta a esta conculcación de los derechos del contribuyente".

Debemos comenzar recordando la doctrina contenida en la STC del 29 de noviembre de 1999 en la que se exponía:

"En efecto, hemos dicho reiteradamente que la indefensión constitucionalmente relevante es la situación en que, en general, tras la infracción de una norma procesal, se impide a alguna de las partes el derecho a la defensa, eliminando o limitando su potestad, bien de alegar derechos e intereses para que le sean reconocidos, o bien de replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del principio de contradicción (por todas SSTC 89/1986, fundamento jurídico 2º o 145/1990, fundamento jurídico 3º), y que esta indefensión ha de tener un carácter material y no meramente formal, lo que implica que no es suficiente con la existencia de un defecto o infracción procesal, sino que debe haberse producido un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa (SSTC 90/1988, fundamento jurídico 2º y 26/1999, fundamento jurídico 3º). Por último, la situación de indefensión debe ser imputable al órgano jurisdiccional, no produciéndose tal consecuencia cuando fue fruto del desinterés, pasividad, malicia o falta de diligencia de quien la denuncia (SSTC 50/1991, fundamento jurídico 5º y 334/1993, fundamento jurídico 2º)."

En el presente caso, llama la atención a la continua referencia a las alegaciones y documental dejadas de aportar y a la indefensión producida, pero en ningún momento se procede a concretar que ausencia de alegaciones se han dejado de hacer o que documental no ha sido aportada y en que sentido se le ha producido a la parte.

Al respecto, llama la atención que de haberse producido la indefensión alegada, no se haya interesado en el presente recurso el recibimiento a prueba a los efectos de poder aportar la documental cuya ausencia ha causado a la parte la referida indefensión.

En consecuencia, fuera de los supuestos de nulidad de pleno derecho, sólo tienen alcance anulatorio aquellas infracciones del procedimiento que hayan dejado al interesado en una situación de indefensión real o material. En este último sentido, cabe recordar que constituye jurisprudencia reiterada la que mantiene que, en las infracciones procedimentales, sólo procede la anulación del acto cuando tales infracciones supongan una disminución efectiva, real y trascendente de garantías, incidiendo en la resolución de fondo, de forma que puedan alterar su sentido, sin que, en cambio, sea procedente la anulación del acto por omisión de un trámite preceptivo cuando, aún cumplido este trámite, se puede prever lógicamente que volvería a producirse un acto administrativo igual al que se pretende anular, o cuando la omisión de un trámite no cause indefensión al interesado, indefensión que no existe si, a pesar de la omisión de aquél, se ha tenido ocasión de alegar a lo largo del procedimiento administrativo, o en vía del recurso administrativo o jurisdiccional, todo lo que no se pudo alegar al omitirse dicho trámite (así, sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2012 -casación 2144/2009- y de 20 de enero de 2016 -casación 286/2014-).

Cuestión distinta es que tales alegaciones y documental no haya servido para que la Administración tributaria estime su pretensión. En tal sentido, lo importante es que se haya dado respuesta a todas las pretensiones de la parte y que ésta conozca los motivos por los que aquellas fueron desestimadas.

En tal sentido, cabe recordar la doctrina contenida en la STC 9/2015, de 2 de febrero de 2015 en la que se exponía lo siguiente:

"El encuadramiento de la vulneración constitucional denunciada en el ámbito del derecho a obtener una respuesta judicial motivada y fundada en Derecho (art. 24.1 CE) exige recordar que, según reiterada doctrina constitucional, el deber de motivación que pesa sobre los órganos judiciales "no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se debate, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundadores de la decisión o, lo que es lo mismo, la ratio decidendi, de manera que no existe un derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial" (entre otras muchas,

SSTC 144/2007, de 18 de junio, FJ 3, y 126/2013, de 3 de junio, FJ 3), pudiendo satisfacerse las exigencias constitucionales mínimas del derecho a la tutela judicial efectiva con una respuesta tácita siempre que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución pueda deducirse no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida sino, además, los motivos de esa respuesta tácita; sin que la suficiencia de la motivación pueda ser "apreciada apriorísticamente, con criterios generales sino que, por el contrario, requiere examinar el caso concreto para comprobar si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido o no este requisito en las resoluciones judiciales" impugnadas (SSTC 314/2005, de 12 de diciembre, FJ 4; y 160/2009, de 29 de junio, FJ 6). En particular debe recordarse que la doctrina constitucional ha declarado reiteradamente que "el silencio judicial determinante de la vulneración constitucional debe referirse a extremos que de haber sido considerados en la decisión hubieran podido determinar un fallo distinto al pronunciado, pues en caso contrario la falta de respuesta carecería de relevancia material" (STC 139/2009, de 15 de junio, FJ 2), y que aunque no existe obligación de que el órgano judicial realice un pronunciamiento explícito sobre la eficacia probatoria que le merece cada uno de los medios de prueba sí es necesario que especifique el discurso que enlaza la actividad probatoria con el relato fáctico resultante (entre otras, STC 126/2013, de 3 de junio, FJ 3). (FJ 3)."

Todo lo expuesto nos lleva a la desestimación de esta primera pretensión de nulidad.

QUINTO.- De terminación de la residencia del recurrente.

El Acuerdo de liquidación procede a determinar que el recurrente ha estado en España mas de 183 días en base a las entradas y salidas que constan en el Certificado de la Administración de EEUU y el Certificado Migratorio expedido en Lima (Perú) el 5 de mayo de 2014, de los que se deduce que ha estado ente Miami y Perú un total de 126 días, por los que el resto de los días ha estado en España.

Además, la residencia en España se deduce de las siguientes pruebas:

1.-) El NIF NUM003 se solicitó por el interesado con fecha 06-09-1990. Su primer domicilio fiscal se estableció en la CALLE000 nº NUM004 de Madrid, hasta el 02-02-2011 que se traslada a CALLE001 nº NUM005 de Madrid. Y en la misma fecha, se modifica nuevamente a la CALLE002 nº NUM006 de DIRECCION001 (Madrid).

2.-) D. Epifanio además consta dado de alta en el padrón del INE en la CALLE000 nº NUM004 de Madrid hasta el 18-03-2011.

3.-) Con fecha 12 de mayo de 2014 se solicita al Servicio de Verificación de Datos de Identidad del MAP petición sobre la situación de ambos números, resultando que D. Epifanio consta en el NIE NUM002 como de nacionalidad peruana y residente en CALLE001 nº NUM005 de Madrid; y en el NIF NUM003 como de nacionalidad española y también residente en CALLE001 nº NUM005 de Madrid.

En ambos casos a efectos de la base de datos de la Policía consta que D. Epifanio es residente en territorio español. Por tanto, si su residencia civil se localiza en territorio español cabe suponer que su residencia fiscal se localiza también en territorio español.

4.-) El domicilio a efectos del NIF de D. Epifanio se establece en CALLE000 nº NUM004 de Madrid y así igualmente consta empadronado en dicho domicilio hasta el 18-03-2011.

Mediante requerimiento de información realizado a la mercantil INMODOMOS SL, se aporta contrato de arrendamiento de fecha 01 de enero de 2009 suscrito por D. Epifanio de un piso en la CALLE000 nº NUM007 de Madrid, así como dos plazas de garaje y un trastero. La renta mensual se fija en 4.800 euros/mensuales y en 2011, por la subida del IPC asciende a 4.910 euros/mensuales. Se aporta además las facturas correspondientes al ejercicio 2011 donde se puede observar el pago de la renta y también, los gastos de agua realizados.

5.-) Consta en el modelo 347 del ejercicio 2011 una imputación de cobros realizada por ENDESA.

6.-) Mediante escritura pública de fecha 28-10-2011 otorgada ante el notario de Madrid D. Luís Pérez-Escolar Hernando, con número de su protocolo 2181; D. Epifanio adquiere un inmueble en la CALLE003 nº NUM008 de Madrid por importe de 2.600.000 euros.

7.-) En diligencia de notificación de fecha 11 de abril de 2011 se hace constar en diligencia que "nos atiende una empleada de hogar que manifiesta que el obligado tributario tiene su domicilio en la CALLE003 nº NUM008 - NUM009 y que en estos momentos no se encuentra en el domicilio".

Dicha empleada del hogar se identifica como Dª. Crescencia (NUM010) que, según consta en la Base de datos de la AEAT sobre información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social, está dada de alta en el Régimen General de Empleados del Hogar, siendo su empleador D. Epifanio .

8.-) La sociedad URBANO MUDANZAS SL declara cobros de D. Epifanio . Mediante requerimiento a la sociedad se aporta contrato suscrito por D. Epifanio de un guardamuebles con fecha 18-11-1998 y donde deposita 248 artículos por un valor de 40 millones de pesetas (240.404,84 euros).

Por último, se hace destacar que la pasividad probatoria del contribuyente provoca la aplicación de los criterios de la permanencia en territorio español.

De contrario, se alega Durante el procedimiento inspector no se ha acreditado que disponga de medios económicos en España, no hay rentas, no ha saldos bancarios, no hay rendimientos mobiliarios, no hay actividad económica. Al respecto, se alega que el pago de alquiler de un guardamuebles desde 1998 con más de doscientos artículos y valor de más de 240.000 euros demuestra que no reside en España, pues si lo hiciera, ya que de lo contrario no pagaría dicho alquiler y tendría esos bienes en su domicilio.

Se añade que: 1) del Certificado de la Administración de EEUU se constata, igualmente, que durante los años 2012 y 2013 a permanencia fuera de España fue superior a 183 días. 2) Que el gasto de luz acreditado por Endesa (consumo de todo el año) se refiere a un inmueble vendido en febrero de 2011. 3) Lo mismo sucede con la imputación por consumo de agua, cuando se trata de una cuota mensual fija de 30 euros. 4) Se han adjuntado las copias de los pasaportes y no constan los sellos de entrada y salida del territorio Español. Sin embargo, sí constan fechas de salida de Perú a Estados Unidos, donde es obligatorio reflejarlo. 5) Carece de actividad económica en España, ni rentas ni saldos bancarios.

SEXTO.- El art. 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece:

"1. Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español. Para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. En el supuesto de países o territorios considerados como paraíso fiscal, la Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en éste durante 183 días en el año natural.

Para determinar el período de permanencia al que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las estancias temporales en España que sean consecuencia de las obligaciones contraídas en acuerdos de colaboración cultural o humanitaria, a título gratuito, con las Administraciones públicas españolas.

b) Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, resida habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél."

Se argumenta por la recurrente, tras cuestionar la prueba la aportada por la Inspección Tributaria que no se ha acreditado la permanencia en España por mas de 183 días en los años 200/, 2009 y 2010.

Al respecto, la Inspección tributaria parte de que el recurrente ha estado en España por el hecho de que constando solo la permanencia en Perú y en Estados Unidos por un periodo de 126 días, el resto del año ha permanecido en España.

Dicho presupuesto de partida no se soporta en ninguna circunstancia de la cual se pueda llegar a tal conclusión, pudiendo el recurrente haber permanecido en cualquier otro país, en el presente caso Perú el resto del año. Hay que poner de manifiesto que por la Administración tributaria, con la finalidad de acreditar tal extremo, le hubiera sido muy fácil aportar el pasaporte del recurrente donde constaran los sellos de entrada y salida de España, pudiendo deducirse de tal documento la permanencia del recurrente en España por mas de 183 días. Es de notar que si bien la Administración Tributaria contabiliza los días de permanencia en Perú y Estados Unidos en base al contenido de los certificados emitidos por ambos países, si bien en dichos documentos no se hace constar las entradas y salidas de España. Así, quedan sin determinar residencia del recurrente durante los periodos 1/01/2011-21/02/2011, 17/03/2011-17/06/2011 y 6/09/2011- 10/12/2011.

A los efectos de determinar que el resto de los días que no consta que el obligado tributario estuviera ni en Perú ni en Estados Unidos, se encontraba en España se acude por la Inspección a distintos indicios antes mencionados.

Pues bien, de los mismos no se puede llegar a la conclusión de que el recurrente se encontrara en España.

De esta manera, ni la certificación en el padrón del INE en la CALLE000 nº NUM004 de Madrid hasta el 18-03-2011, ni que a efectos de la base de datos de la Policía consta que D. Epifanio es residente en territorio español, pueden ser consideradas pruebas fehacientes de su residencia en España.

Tampoco es prueba de la residencia en España que D. Epifanio conste en el NIE NUM002 como de nacionalidad peruana y residente en CALLE001 nº NUM005 de Madrid; y en el NIF NUM003 como de nacionalidad española y también residente en CALLE001 nº NUM005 de Madrid.

La existencia de un contrato de arrendamiento de una vivienda en Madrid (CALLE000 nº NUM007) tampoco sirve por si mismo para acreditar la residencia en España por mas de 183 días. Lo mismo cabe afirmar de la compra de una vivienda en la CALLE003 de Madrid.

Por último, el arrendamiento de un guardamuebles con fecha 18-11-1998 tampoco sirve para acreditar la residencia efectiva del recurrente en España, sirviendo tal prueba para acreditar, igualmente, su estancia fuera del país.

A su vez, consta en el expediente administrativo los gastos por el consumo de agua, que quitando los tres primeros meses, se corresponde con una cuota mensual de 30 €.

Por último, carece de sentido hablar de una pasividad probatoria por parte del recurrente ante la débil prueba aportada con la finalidad de acreditar la residencia efectiva en España por mas de 183 días. No se han aportado facturas de suministros diversos como consecuencia de desarrollar la vida diaria en España, no se ha aportado documentación bancaria de la cual deducir la existencia de gastos realizados en el país, no se ha acreditado que el recurrente tuviera su vivienda habitual en la CALLE003 . Todo lo contrario, cuando se acudió a dicha vivienda a efectos de realizar una notificación, se hizo constar que estaba ausente. Por último, no se ha acreditado que el recurrente tuviera en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

En definitiva, la prueba aportada por la Inspección tributaria no tiene entidad suficiente para deducir de la misma que el ahora recurrente residía en España los días que no estaba ni en Estados Unidos ni en Perú.

Conviene recordar que en materia de residencia fiscal corresponde a la Administración aportar datos de los que se infiera la existencia de domicilio fiscal en España de conformidad con lo establecido en la Ley, y si tales indicios son suficientes, corresponde al obligado tributario, demostrar su residencia en otro Estado.

En esta línea, la STS de 16 de junio y 13 de octubre de 2011 (Rec. 4029 y 2283/2008), recuerda que es doctrina constante de la Sala que "establecida la presunción ["se entenderá"], correspondía a la parte demostrar la residencia en otro Estado". Regla que no es sino una razonable aplicación de la distribución de la carga de la prueba en materia tributaria, pues siendo cierto que corresponde a la Administración probar "los hechos en que descansa la liquidación impugnada", no lo es menos que "cuando la liquidación tributaria se funda en las actuaciones inspectoras practicadas, que constan debidamente documentadas, es al contribuyente a quien incumbe desvirtuar las conclusiones alcanzadas por la Administración". Y así, en la STS de 16 de junio de 2011 (Rec. 4029/2008) se sostiene que es obligación del "sujeto sometido a comprobación de probar su residencia fuera de España cuando la Administración lo ha considerado residente en nuestro territorio". Lógicamente porque se ha probado la existencia de sólidos indicios que llevan a tal conclusión.

Recuérdese, por lo demás, que una vez acreditada la residencia en España por más de 183 días durante el año natural -normalmente por pruebas indiciarias o indirectas-, al no tenerse en cuenta las "ausencias esporádicas", es necesario que el contribuyente acredite su "residencia fiscal" en otro país.

También ha indicado la Sala, entre otras en su STS de 11 de noviembre de 2009 (Rec. 8294/2003) que, en relación con el concepto de residencia, se exige, de un lado, "un elemento espiritual, la "intención" de residir en un lugar determinado. De otra parte, es necesario que se dé un elemento material, la residencia efectiva. La doctrina de la Sala 1ª sobre este problema ha vacilado entre dar relevancia al elemento subjetivo o al objetivo. En materia fiscal y para el legislador de 1978 no ofrece dudas que el elemento relevante es el elemento objetivo. Por eso el artículo....alude al elemento objetivo de la "permanencia" como rasgo definidor de la residencia".

En cuanto al criterio del "centro de intereses económicos" y personales -"se presumirá...que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando....residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél"-, la jurisprudencia pondera la importancia del patrimonio económico y la actividad económica desplegada - STS 4 de julio de 2006 (Rec. 955/2010)-.

A la vista de la prueba aportada por la Administración tributaria es evidente que no existen indicios suficientes para determinar que el obligado tributario residió en España más de 183 días en el año 2011, por lo que no tiene éste la obligación de aportar prueba que sirva para desvirtuar los datos aportados por la Administración.



La estimación de este motivo por no haberse acreditado la residencia efectiva en España por mas de 183 días, no es necesario entrar a analizar el resto de las pretensiones planteadas en la demanda.

SEPTIMO.- La estimación del recurso determina que las costas se impongan a la parte demandada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LJCA.

VISTOS los preceptos constitucionales y legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo nº 661/2019 interpuesto por la representación procesal de Don Matías, como sucesor de D. Epifanio, contra la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Central de 11 de marzo de 2019, la cual procedemos a anular.

Con imposición de costas a la parte demandada.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casaciones objetivo que presenta.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La anterior Sentencia ha sido publicada en la fecha que consta en el sistema informático. Doy fe.